

1503124-49.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/02/2022
... de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503124-49.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216529/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19542395 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4404/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2216529 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIO CARDOSO DA CRUZ FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JULIO CARDOSO DA CRUZ FILHO está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 168), o réu apresentou defesa (fls. 169/177).

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2021 (fls. 184/185) e o réu foi citado (fls. 231).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 242).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 259/263).

A defesa pugnou pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 287/292).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 43/55), laudo pericial (fls. 126/129), além da prova oral colhida na fase instrutória.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e a propriedade da droga apreendida, argumentando, em suma, que está sendo falsamente incriminado. Disse que, após o trabalho, foi à chácara para levar as sobras de comida para os cachorros. No caminho, passou por um local onde sempre há latinhas de alumínio, as quais costuma recolher, o que fez na ocasião. Ao avistar a viatura do BAEP, empreendeu fuga por medo, pois no dia anterior havia sido abordado e agredido por policiais da mesma corporação. Sua intenção era parar o carro no posto da polícia rodoviária ou onde houvesse mais pessoas, já que ostenta antecedentes criminais. Não viu se passou pelo posto da polícia rodoviária. Não parou no pedágio, pois pretendia parar apenas perto de outros policiais. Não apresentou a referida versão na delegacia por estar muito machucado e apenas disse à autoridade policial que gostaria de ser socorrido. Negou ter passado por rotatória antes de ser abordado e disse dirigiu apenas cerca de cinco minutos após o pedágio, pois o combustível acabou. Afirmou que foi agredido durante a abordagem.

O policial militar Rafael relatou que estava em patrulhamento pelo Bairro Ferradura Mirim, na cidade de Bauru, que é conhecido como ponto de tráfico. Avistou uma caminhonete branca, que, ao se deparar com a viatura, engatou marcha ré e seguiu em sentido contrário, o que despertou suspeita e ensejou a perseguição até a cidade de Jaú, onde acabou o combustível do veículo. Durante a fuga, o acusado atirou alguns objetos pequenos para fora do veículo, todavia não identificou o que era. Apreendeu dinheiro e dois tijolos de maconha (embaixo do banco do carona). O acusado alegou que a droga não estava no veículo. Não conhecia o réu de antemão e foi necessário o uso de força para contê-lo, pois ele tentou se evadir após descer do veículo. Admitiu ter dado socos no acusado e disse que assim agiu porque ele estava resistindo à prisão e atacando os policiais.

O policial militar Luiz confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega e acrescentou que durante a fuga o réu chegou a romper a cancela do pedágio e que ele foi abordado na rodovia que dá acesso a Barra Bonita. Afirmou que havia alguns produtos de reciclagem na caçamba da caminhonete, que chegaram a cair durante a fuga.

A esposa do réu, Michele, informou ter financiado a caminhonete que o réu conduzia no momento da prisão, pois trabalham com reciclagem. Ele também trabalha como pedreiro e a ajuda em uma lanchonete. Não sabe se ele frequenta o bairro onde a perseguição teve início e, desde que estão juntos – fevereiro de 2021 –, ele não apresentou envolvimento com entorpecentes. Um tempo antes da prisão ele foi agredido por policiais durante uma abordagem de rotina.

A testemunha Antônio Marcos narrou trabalhava com o réu como pedreiro e ele ganhava

cerca de R\$110,00 a R\$120,00 ao dia. Sabe, ainda, que ele trabalhava com a esposa em uma lanchonete e tem uma caminhonete.

A testemunha Marcia contou que o acusado usava a caminhonete para transportar recicláveis, mas também executava serviços como pedreiro.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

Os policiais militares apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a abordagem e do encontro dos entorpecentes no veículo. E não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões, até porque o acusado informou que sequer os conhecia.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Ademais, as contradições que permeiam a narrativa do acusado enfraquecem sua negativa. Além de ter afirmado que empreendeu fuga sem que portasse nada de ilícito, o réu alegou que assim agiu com o intuito de encontrar uma base policial, todavia ele foi preso na Rodovia SP 255- Chácara Itaúna - Jaú/SP (pg. 9), após ter passado em frente ao posto da polícia rodoviária estadual localizado na rodovia SP 225, que liga as cidades de Bauru a Jaú, informação que pode ser verificada pelo google maps.

Merece enfoque, ainda, que ele sustentou que pretendia parar onde houvesse mais transeuntes, mas, nada obstante estivesse na zona urbana de Bauru quando foi abordado, empreendeu fuga justamente com sentido à rodovia. Ele tampouco parou no pedágio, um dos poucos lugares na estrada onde poderia haver concentração de pessoas.

No veículo do réu foi encontrada vultosa quantidade de entorpecente, incompatível com o mero uso próprio.

Em adição, o fato do acusado não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Por fim, foi determinada a apuração de eventual uso excessivo de força por parte dos policiais para contenção do réu (pg. 87). E, ainda que ele tivesse ocorrido, não teria o condão de afastar o decreto condenatório, mas apenas de acarretar a responsabilização dos envolvidos.

Nessa toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade de droga apreendida (fls. 12/13). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Presente, ainda, a agravante da reincidência (Proc. 0002793-21.2008 - fls. 213 c.c. 224). Assim, aumento a pena para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu não permite a aplicação da causa de

diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência do réu e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para

fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal - art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu JULIO CARDOSO DA CRUZ FILHO, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 728 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do veículo apreendido com o acusado, pois utilizado na prática delitiva. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA